EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – CFOAB, serviço público dotado de personalidade jurídica e regulamentado pela Lei nº 8.906/94, inscrito no CNPJ sob o nº 33.205.451/0001-14, por seu Presidente, **MARCUS VINICIUS FURTADO COÊLHO**, **vem,** à presença de Vossa Excelência, por intermédio de seus advogado infra-assinados, com instrumento procuratório específico incluso e endereço para intimações na SAUS Qd. 05, Lote 01, Bloco M, Brasília-DF, com base no art. 103, inciso VII e art. 102, inciso I, alínea "a" da Constituição Federal e no art. 2º, inciso VII da Lei nº 9.868/99, propor

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO CAUTELAR

contra **CÂMARA DOS DEPUTADOS**, por intermédio de seu Presidente, com endereço para comunicações no Palácio do Congresso Nacional, Praça dos Três Poderes, Brasília-DF; **SENADO FEDERAL**, por intermédio de seu Presidente, com endereço para comunicações na Praça dos Três Poderes, Brasília-DF; **PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA**, por intermédio de sua Presidenta, com endereço para comunicações no Palácio do Planalto, Praça dos Três Poderes, Brasília-DF, e **CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CNMP,** por intermédio de seu Presidente, com endereço para comunicações no Setor de Administração Federal Sul, SAFS, Quadra 02, Lote 03, Edifício Adail Belmonte, Brasília-DF, CEP 70070-600; todos órgãos/autoridades federais responsáveis, respectivamente, pela elaboração da **Lei nº 8.460/1992,** publicada no Diário Oficial da União de 17.09.1992 e retificado em 18.09.1992; **Lei Complementar nº 75/1993,** publicada no Diário Oficial da União de 21.05.1993; **Lei nº 8.625/1993,** publicada no Diário Oficial da União de 15.02.1993; e **Resolução nº 09/2006,** de 05/06/2009, do CNMP; bem como contra o **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO – MP-PE**, por meio do Procurador-Geral de Justiça, cujo endereço para comunicações é Rua do Imperador D. Pedro II, nº 473, Ed. Roberto Lyra, Santo Antônio, Recife/PE, CEP: 50010-240, órgão/autoridade responsável pela elaboração da **RESOLUÇÃO RES-PGJ Nº 002/2012, de 14 de fevereiro de 2012,** em virtude dos seguintes fundamentos:

I - DA PRÉVIA DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA ANALISADA NESTA AÇÃO:

Insta, desde já, evidenciar que a presente Ação Direta de inconstitucionalidade visa impugnar a instituição em favor dos membros do Ministério Público do Estado de Pernambuco de benesse denominada auxílio-alimentação, **mesmo diante da total e completa ausência de previsão legal acerca do pagamento da mencionada verba.**

Nessa senda, importa narrar que o órgão ministerial pernambucano aprovou a Resolução RES-PGJ nº 002/2012, em 14 de fevereiro de 2012, regulamentando o auxílio-alimentação a seus membros (promotores e procuradores de justiça).

O fundamento para o estabelecimento da malfadada vantagem em benefício dos membros do Ministério Público seguiu a incongruente, *permissa venia*, cadeia de raciocínio:

> a) a Lei nº. 8.460, de 17 de setembro de 1992, estabelece, a todos os servidores públicos federais, em caráter geral, o auxílio-alimentação, nos termos do art. 22[1];

[1] Art. 22. O Poder Executivo disporá sobre a concessão mensal do auxílio-alimentação por dia trabalhado, aos servidores públicos federais civis ativos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 1997)
§ 1º A concessão do auxílio-alimentação será feita em pecúnia e terá caráter indenizatório. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 1997)
§ 2º O servidor que acumule cargo ou emprego na forma da Constituição fará jus a percepção de um único auxílio-alimentação, mediante opção. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 1997)
§ 3º O auxílio-alimentação não será: (Incluído pela Lei nº 9.527, de 1997)
a) incorporado ao vencimento, remuneração, provento ou pensão; (Incluído pela Lei nº 9.527, de 1997)
b) configurado como rendimento tributável e nem sofrerá incidência de contribuição para o Plano de Seguridade Social do servidor público; (Incluído pela Lei nº 9.527, de 1997)
c) caracterizado como salário-utilidade ou prestação salarial *in natura*. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 1997)
4º O auxílio-alimentação será custeado com recursos do órgão ou entidade em que o servidor estiver em exercício, ressalvado o direito de opção pelo órgão ou entidade de origem. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 1997)
§ 5º O auxílio-alimentação é inacumulável com outros de espécie semelhante, tais como auxílio para a cesta básica ou vantagem pessoal originária de qualquer forma de auxílio ou benefício alimentação. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 1997)
§ 6º Considerar-se-á para o desconto do auxílio-alimentação, por dia não trabalhado, a proporcionalidade de 22 dias. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 1997)
§ 7º Para os efeitos deste artigo, considera-se como dia trabalhado a participação do servidor em programa de treinamento regularmente instituído, conferências, congressos, treinamentos, ou outros eventos similares, sem deslocamento da sede. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 1997)
§ 8º As diárias sofrerão desconto correspondente ao auxílio-alimentação a que fizer jus o servidor, exceto aquelas eventualmente pagas em finais de semana e feriados, observada a proporcionalidade prevista no § 6º." (Incluído pela Lei nº 9.527, de 1997)

b) a Lei Complementar Federal 75, de 20 de maio de 1993 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), estabelece, em seu art. 287, que *"Aplicam-se subsidiariamente aos membros do Ministério Público da União as disposições gerais referentes aos servidores públicos, respeitadas, quando for o caso, as normas especiais contidas nesta lei complementar"*;

c) a Lei Federal nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, estabelece, em seu art. 80[2], que se aplicam aos membros do Ministério Público do Estado (MPE), subsidiariamente, as normas da citada Lei Complementar Federal 75/1993; e

d) a Resolução nº 09/2006, de 05 de junho de 2006, editada pelo Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, que sujeita ao teto constitucional, em seu art. 6º, o recebimento de todas as parcelas remuneratórias, inclusive vantagens pessoais, exceto as de caráter indenizatório como o auxílio-alimentação (inciso I, alínea 'b').

Por isso, entendeu o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Pernambuco que aos membros do Ministério Público são devidas as vantagens concedidas aos membros do Ministério Público da União, que são, por sua vez, devidas em função da concessão dessas vantagens aos demais servidores públicos, em caráter geral.

Em razão desse raciocínio foi editada a **Resolução RES-PGJ nº 002/2012**, ora impugnada, a qual disciplinou a aplicação do auxílio-alimentação aos membros do MPPE (promotores e procuradores de Justiça) por serem, subsidiariamente, aplicáveis a eles as mesmas disposições aplicáveis aos membros do MPU, que, por sua vez, já interpretou extensivamente outra norma para trazer para si as vantagens aplicáveis aos demais servidores públicos federais.

Sendo assim, **os mencionados atos normativos,** com base apenas em sucessivas remissões, **foram além do que está previsto na Constituição e nas próprias normas "subsidiantes", uma vez que a criação de novas vantagens só poderia ocorrer mediante lei em sentido formal**.

[2] Art. 80. Aplicam-se aos Ministérios Públicos dos Estados, subsidiariamente, as normas da Lei Orgânica do Ministério Público da União.

Impera, pois, na forma da fundamentação jurídica a ser adequadamente aduzida no decorrer desta manifestação, que essa e. Corte confira a condigna **interpretação conforme** às normas extensivamente interpretadas em favor do Ministério Público do Estado de Pernambuco e expurgue de nosso ordenamento a Resolução vergastada.

Ante o exposto, e devidamente delimitada a temática objeto de irresignação, cabe ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - CFOAB, como legitimado universal para a propositura de Ação Direta de inconstitucionalidade e, portanto, defensor da cidadania e da Constituição, no exercício de sua competência legal (Art. 44, inciso I da Lei nº 8.906/94), comparecer ao guardião da Carta Magna para impugnar os dispositivos a seguir arrolados, pleiteando a declaração de sua inconstitucionalidade e consequente afastamento do sistema jurídico.

Feitas essas considerações, passa-se a demonstrar a inconstitucionalidade das normas combatidas, vejamos:

II - DAS NORMAS IMPUGNADAS - DA CONFIGURAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CONSEQUENCIAL – ARRASTAMENTO:

Com efeito, a **Lei Federal nº 8.460/1992** confere antecipação de reajuste de vencimentos e de soldos dos **servidores civis e militares do Poder Executivo** e dá outras providências. Possui os seguintes dispositivos, ora impugnados em razão da interpretação extensiva deles retirada pelo MP-PE:

> ***Art. 22.*** *O* ***Poder Executivo disporá sobre a concessão mensal do auxílio-alimentação*** *por dia trabalhado,* ***aos servidores públicos federais civis ativos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional****. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 1997)*
> Grifos nossos.
>
> *§ 1º A concessão do auxílio-alimentação será feita em pecúnia e terá caráter indenizatório. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 1997)*
>
> *§ 2º O servidor que acumule cargo ou emprego na forma da Constituição fará jus a percepção de um único auxílio-alimentação, mediante opção. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 1997)*

§ 3º O auxílio-alimentação não será: (Incluído pela Lei nº 9.527, de 1997)
a) incorporado ao vencimento, remuneração, provento ou pensão; (Incluído pela Lei nº 9.527, de 1997)
b) configurado como rendimento tributável e nem sofrerá incidência de contribuição para o Plano de Seguridade Social do servidor público; (Incluído pela Lei nº 9.527, de 1997)
c) caracterizado como salário-utilidade ou prestação salarial in natura.(Incluído pela Lei nº 9.527, de 1997)

§ 4º O auxílio-alimentação será custeado com recursos do órgão ou entidade em que o servidor estiver em exercício, ressalvado o direito de opção pelo órgão ou entidade de origem. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 1997)

§ 5º O auxílio-alimentação é inacumulável com outros de espécie semelhante, tais como auxílio para a cesta básica ou vantagem pessoal originária de qualquer forma de auxílio ou benefício alimentação. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 1997)

§ 6º Considerar-se-á para o desconto do auxílio-alimentação, por dia não trabalhado, a proporcionalidade de 22 dias. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 1997)

§ 7º Para os efeitos deste artigo, considera-se como dia trabalhado a participação do servidor em programa de treinamento regularmente instituído, conferências, congressos, treinamentos, ou outros eventos similares, sem deslocamento da sede. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 1997)

§ 8º As diárias sofrerão desconto correspondente ao auxílio-alimentação a que fizer jus o servidor, exceto aquelas eventualmente pagas em finais de semana e feriados, observada a proporcionalidade prevista no § 6º." (Incluído pela Lei nº 9.527, de 1997).

Por outro lado, a **Lei Federal nº 8.625/1993** cria *"a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, dispõe sobre normas gerais para a organização do Ministério Público dos Estados e dá outras providências"*, sendo combatido o dispositivo abaixo citado:

Art. 50. Além dos vencimentos, poderão ser outorgadas, a membro do Ministério Público, nos termos da lei, as seguintes vantagens:
(...)

> *XII - outras vantagens previstas em lei, inclusive as concedidas aos servidores públicos em geral.*
>
> *Art. 80. Aplicam-se aos Ministérios Públicos dos Estados, subsidiariamente, as normas da Lei Orgânica do Ministério Público da União.*

Já a **Lei Complementar nº 75/1993** assenta *"a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União"*, restando atacados os artigos:

> *Art. 224. Os membros do Ministério Público da União receberão o vencimento, a representação e as gratificações previstas em lei.*
>
> *Art. 287. Aplicam-se subsidiariamente aos membros do Ministério Público da União as disposições gerais referentes aos servidores públicos, respeitadas, quando for o caso, as normas especiais contidas nesta lei complementar.*
>
> *§ 1º O regime de remuneração estabelecido nesta lei complementar não prejudica a percepção de vantagens concedidas, em caráter geral, aos servidores públicos civis da União.*

A Resolução nº 09/2006, editada pelo Conselho Nacional do Ministério Público – CNPM, lado outro, assim prevê o benefício:

> *Art. 6º Estão sujeitas ao teto constitucional todas as parcelas remuneratórias, inclusive as vantagens pessoais, exceto as seguintes verbas:*
> *I – de caráter indenizatório:*
> *(...)*
> *b) auxílio-alimentação;*

Por fim, nos termos já aduzidos, compete ao Requerente impugnar a **íntegra da Resolução do Ministério Público Estadual de Pernambuco RES-PGJ nº 002/2012**, que por uma aplicação subsidiária e extensiva das normas supramencionadas estabeleceu o auxílio-alimentação a seus membros:

> ***RESOLUÇÃO RES-PGJ Nº 002/2012***
> *Regulamenta a concessão do auxílio-alimentação para os Membros ativos do Ministério Público do Estado de Pernambuco.*

*O **PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO**, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 9º, V, da Lei Complementar nº 12, de 27 de dezembro de 1994, ouvindo o Colendo Colégio Procuradores de Justiça; e*

***CONSIDERANDO** que a Lei Complementar nº 75, de de maio de 1993, em seu art. 287, § 1º, estabelece que "o regime de remuneração estabelecido nesta lei complementar não prejudica a percepção de vantagens concedidas, em caráter geral, aos servidores públicos civis da União";*

***CONSIDERANDO** que os servidores públicos civis da união têm direito ao auxílio-alimentação garantido em virtude da Lei Federal nº 8.460, de 17 de setembro de 1992;*

***CONSIDERANDO** que a Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, aplica-se subsidirariamente ao Ministério Público do Estado de Pernambuco, na forma do art. 80 da Lei Federal nº 8.625/93;*

***CONSIDERANDO** que o Ministério Público Federal recebe auxílio-alimentação desde o primeiro semestre de 1993, em virtude da Portaria nº 586, de 18 de dezembro de 1992;*

***CONSIDERANDO** que o Conselho Nacional do Ministério Público, através da Resolução nº 09, de 05 de junho de 2006, reconheceu o caráter indenizatório do auxílio-alimentação;*

***CONSIDERANDO** o caráter unitário e nacional do Ministério Público, reconhecido pelo Conselho Nacional do Ministério Público no julgamento do Pedido de Providência nº 899/2009-15;*

***CONSIDERANDO** que o Conselho Nacional do Ministério Público, no julgamento do Procedimento de Controle Administrativo nº 0.00.000.000447/2011-40, reconheceu a inexistência de ilegalidade no ato administrativo que concede auxílio-alimentação a Membros do Ministério Público;*

***CONSIDERANDO** que, em sessão ocorrida no dia 13 de fevereiro de 2012, o Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do Estado de Pernambuco manifestou-se favoravelmente ao pagamento de auxílio-alimentação aos Membros do Ministério Público do Estado de Pernambuco;*

***RESOLVE**:*

Art. 1º. Conceder auxílio-alimentação para os Membros ativos do Ministério Público do Estado de Pernambuco, de caráter indenizatório, que será pago em pecúnia, mensalmente, na data do pagamento, referente ao mês subsequente.
Parágrafo único. O auxílio-alimentação destina-se a subsidiar as despesas com alimentação do Membro ativo do Ministério Público do Estado de Pernambuco.

Art. 2º. O valor do auxílio-alimentação será fixado por ato do Procurador-Geral de Justiça.

Art. 3º. O auxílio-alimentação não é rendimento tributável, não constitui base de incidência de contribuição previdenciária, nem base de cálculo para fins de margem consignável, e não integra o subsídio.

Art. 4º. O auxílio-alimentação, em razão de sua natureza indenizatória, não poderá ser incorporado ao subsídio ou à vantagem de qualquer natureza.

Art. 5º. O pagamento do auxílio alimentação, na forma desta Resolução, deverá ser implementado a partir de 1º de março de 2012.

Art. 6º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Recife, 14 de fevereiro de 2012.

AGUINALDO FENELON DE BARROS
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

É de bom grado, neste momento, estabelecer uma pequena ressalva apenas para destacar que a Resolução em voga, ante sua natureza de ato não autônomo, secundário e dependente das demais normas ora atacadas, não se mostra sujeito, isoladamente, ao controle concentrado de constitucionalidade aqui proposto, razão pela qual forçosa se mostra, *data venia*, seja dada interpretação conforme à Constituição Federal às demais normas vergastadas de modo a fulminar a constitucionalidade da Resolução citada.

Pois bem. Nos termos insistentemente já explicitados, a Resolução RES-PGJ Nº 002/2012 criou e regulamentou o auxílio-alimentação em favor do MP-PE aqui contestado, somente embasado em interpretações extensivas no sentido de que fariam jus a este benefício em função de os membros do Ministério Público da União supostamente também o fazerem,

estes últimos em virtude de mais uma interpretação extensiva respaldada na legislação dos servidores públicos federais.

Assim, a inconstitucionalidade perseguida nesta Ação Direta se resume na irrefutável, com o devido acatamento, necessidade de que esse e. Pretório dê **interpretação conforme à Constituição Federal** aos dispositivos contidos nas leis supra referidas para consignar/declarar:

> *** Que o auxílio-alimentação subsidiariamente conferido aos membros do Ministério Público da União não se aplica AUTOMATICAMENTE aos membros do Ministério Público dos Estados, restando indispensável a edição de lei em sentido estrito para esse desiderato.**

Uma vez conferida interpretação conforme aos dispositivos hostilizados na forma acima requerida, mandatório, *concessa venia*, se torna a declaração de inconstitucionalidade da íntegra da Resolução RES-PGJ Nº 002/2012 **por arrastamento/inconstitucionalidade consequencial**.

É que o vínculo da conexão justifica a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento da íntegra da Resolução, porquanto há situação de mútua dependência normativa, considerando, ainda, que os dispositivos legais ora questionados se interagem, daí porque a decisão desse Eg. Tribunal há de contemplar – pela unidade estrutural – a análise sistêmica da questão de fundo.

Tudo isso posto, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil requer, desde já, seja dada interpretação conforme à Constituição Federal, nos termos supra oferecidos, aos dispositivos questionados, bem como seja declarada a inconstitucionalidade, **por arrastamento,** da íntegra da Resolução RES-PGJ Nº 002/2012 do Ministério Público Estadual de Pernambuco.

III - FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

III.I – DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO FEDERATIVO:

De acordo com o princípio federativo, é vedada a vinculação automática, aos servidores estaduais, de vantagens recebidas por servidores federais, previstas em leis federais.

Em verdade, **não** poderia o Estado-membro que possui capacidade de autolegislação e que detém a realidade específica de suas receitas e despesas ficar refém da política salarial (remuneração e vantagens) aplicada aos servidores federais.

> *Integrantes da Federação, os Estados-Membros também são dotados de autonomia política, administrativa e de competência para legislar, e são pessoas jurídicas de direito público interno.*
> ***A competência para o governo próprio e a competência pra legislar é que estabelecem a distinção entre o Estado unitário e o Estado federal**, já que a autonomia que lhes é deferida é exercida sem concessão pelo poder central (não há poder do Estado por concessão da União). Detêm, no entanto, apenas autonomia (e não soberania), o que resulta a necessidade de atendimento das diretrizes fixadas antes na Constituição da República.*
> (CHIMENTI, Ricardo Cunha et al. *Curso de Direito Constitucional*. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 179/180, grifo nosso).

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou em julgado que, *mutatis mutandis*, aplica-se ao caso:

> ***AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1237/RJ.***
> *Ementa: É contrário ao princípio federativo (art. 25 da constituição federal) o estabelecimento de equiparação ou vinculação entre servidores (civis ou militares) estaduais e federais, de modo a que do aumento de remuneração concedido, aos últimos, por lei da união, pudesse resultar majoração de despesa para os estados.*

Nessa senda, indaga-se: caso hipoteticamente houver no futuro uma lei estabelecendo certa vantagem aos servidores públicos federais isto seria devido também aos promotores e procuradores de Justiça? Obviamente que não, posto que representa uma direta ofensa ao princípio federativo.

A forma federativa de Estado é cláusula pétrea (art. 60, § 4º, da Constituição Federal), de modo que um Estado Federado tem como uma de suas características principais o respeito à autonomia dos entes que o compõem, dentre os quais está o Estado-Membro (art. 18, *caput*, da Constituição Federal): "*Sem autonomia não se pode falar em Estado-membro, pois ela configura o seu elemento essencial* […]" [3].

[3] BULOS, Uadi Lammêgo. *Constituição Federal anotada*. 9. ed. rev. e atual. até a Emenda Constitucional n. 57/2008. São Paulo: Saraiva: 2009.

A autonomia do Estado-Membro, na qualidade de ente federado, consubstancia-se pela possibilidade de autogerenciamento, respeitando, evidentemente, as normas que exsurgem da Lei Maior do país.

E nem se diga que o princípio da unidade do Ministério Público (art. 127, §1º, da CF/88) poderia legitimar a simetria, no sentido ora impugnado, entre o membro do MPU e do MP-PE, pois a mencionada unidade é relacionada à atuação funcional, e não à percepção de vantagens ou padrões remuneratórios.

Com isso, as normas impugnadas, notadamente o art. 80 da Lei nº 8.625/1993, não podem ser interpretadas em completa dissociação do sistema constitucional. Devem ser interpretados à luz das demais normas constitucionais, inclusive a que estabelece a autonomia dos Estados-Membros, encartada no art. 25 da Constituição Federal de 1988.

Destarte, eis a primeira inconstitucionalidade contida no ato impugnado:

> * O Estado de Pernambuco não tem obrigação de reproduzir vantagens aos membros do MP-PE que sejam eventualmente aplicáveis aos membros do MPU, concedidas por leis federais. Tal obrigação, de reprodução automática, consubstancia-se como uma **violação ao artigo 25 da Carta Política que reforça o chamado "princípio federativo" previsto no art. 1º da Carta da República, também violado**.

E tal exegese decorre do balizamento efetuado pelo e. Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP ao reconhecer o caráter indenizatório do auxílio-alimentação, na forma do art. 6º, inciso I, alínea 'b', da Resolução nº 09/2006, suso indicada.

Isto é, o e. CNMP, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo nº 0.00.000.000447/2011-40, entendeu que o regime remuneratório aplicável dos integrantes do Ministério Público admite a concessão de verbas de caráter indenizatório e isso não implica em desrespeito à regra do subsídio, conforme seguinte trecho:

> *"(...)*
> *Discordo, também, data máxima venia, do entendimento exarado no voto-vista do Exmo. Conselheiro Luiz Moreira Gomes Júnior, uma vez*

que a concessão de verbas de caráter indenizatório não violam a regra do subsídio.
Vale lembrar que a figura jurídica do subsídio, como instrumento de política remuneratória da Administração Pública Federal, foi introduzida pela Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, que estabeleceu esse conceito nos termos da redação que conferiu ao novo § 4º do art. 39:
(...)
Trata-se, portanto, de forma de composição dirigida, essencialmente, aos agentes políticos, ocupantes de cargos públicos intrínsecos à estrutura do Estado como forma de expressão dos Poderes da República, nos três níveis de Governo, evitando-se, assim, que sua remuneração seja contaminada pela concessão de vantagens que retirem transparência da respectiva composição, conferindo a esses agentes públicos uma retribuição fixada em parcela única, sem que quaisquer outras vantagens lhes possam ser acrescidas, e sujeita aos princípios da revisão geral anual, fixação por meio de lei e teto de remuneração aplicável a cada esfera de Governo.
No entanto, essa espécie remuneratória fixada em parcela única não afasta a possibilidade de concessão de vantagens que não tenham cunho remuneratório, como é o caso do auxílio-alimentação. Essa é a previsão contida no art. 57, § 7º, da CF, in verbis:
(...)
O citado § 7º do art. 57 da CF prevê a expressamente a possibilidade de pagamento de parcela de natureza indenizatória, desde que não sejam superiores ao do subsídio mensal, de onde se depreende que o Constituinte diferenciou claramente os institutos, sendo que as parcelas indenizatórias não são alcançadas pela vedação imposta pelo art. 39, § 4º.
Pensar em sentido contrário seria impossibilitar até mesmo o pagamento de diárias àqueles que são remunerados por subsídio, uma vez que as diárias também tem caráter indenizatório.
Conclui-se, portanto, que a Constituição Federal distinguiu entre as espécies remuneratórias e as parcelas de natureza indenizatória, inexistindo qualquer impedimento para o pagamento de auxílio-alimentação em acréscimo ao subsídio.
(...)"

Como se vê, 'data venia' ao entendimento, tomou-se indevidamente como parâmetro o § 7º do art. 57 da Carta Magna --- que cuida especificamente das sessões extraordinárias do Congresso Nacional --- para justificar a possibilidade de acumulação do subsídio definido no art. 39, § 4º (e

aplicável aos membros do Ministério Público por força do art. 128, § 5º, alínea 'c') com o recebimento do benefício auxílio-alimentação.

É dizer, em outras palavras, que essa construção hermenêutica subverteu a regra do subsídio em parcela única e aplicou dispositivo constitucional relacionado às sessões do Congresso Nacional.

Com todo respeito, o § 7º do art. 57 da Constituição Federal em nada se assemelha ao regime remuneratório dos integrantes do Ministério Público, sendo manifestamente imprópria a interpretação efetuada como forma de justificar a possibilidade de acumulação do subsídio com a parcela auxílio-alimentação, daí a impugnação da Resolução do e. CNMP.

Impera, pois, seja dada interpretação conforme ao art. 22 'caput' e §§ 1º ao 3º, alíneas "a", "b", "c", e §§ 4º ao 8º da Lei Federal nº 8.460/92; bem assim ao art. 50 'caput' e inciso XII e art. 80 da Lei Federal nº 8.625/1993; aos arts. 224 e 287 'caput' e § 1º da Lei Complementar nº 75/93, nos termos já requeridos e, por consequência, declaradas inconstitucionais as Resoluções atacadas.

III.II – DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL:

Prosseguindo no exame da Lei Federal nº 8.625/93, utilizada como balizadora da inconstitucional benesse aqui guerreada, impõe-se a citação do artigo 50, o qual estabelece:

> *Art. 50. Além dos vencimentos, poderão ser outorgadas, a membro do Ministério Público, nos termos da lei, as seguintes vantagens:*
> *[...]*
> *XII - outras vantagens previstas em lei, inclusive as concedidas aos servidores públicos em geral.*

Nada obstante, parece-nos que o dispositivo acima pode ser interpretado de duas formas.

Pela primeira, poder-se-ia entender que uma vez previsto na Lei Federal nº 8.460/1992 o auxílio-alimentação para os servidores públicos civis da União, tal vantagem seria automaticamente extensiva aos membros dos Ministérios Públicos. Assim, a exigência da reserva de lei estaria satisfeita em razão do estatuto legal dos servidores civis da União.

Pela segunda interpretação possível, 'data venia', os mesmos dispositivos apenas permitem que, tanto no âmbito do MPU quanto no dos MPEs, possam ser criadas, por lei específica, vantagens que já existem, também por lei, para os servidores públicos civis da União. Assim, se os servidores federais recebem auxílio-alimentação, cada Estado poderia, por lei, estender esse benefício aos membros do respectivo MP.

Manifesto, por conseguinte, que a primeira interpretação é incompatível com a Constituição Federal. Explique-se.

Em primeiro lugar, atrelar de forma automática o regime de remuneração e vantagens dos membros do MP ao dos servidores civis da União seria mesclar de tal forma as carreiras que violaria a ideia de legalidade do *caput do art.* 37, bem como o da reserva legal, do § 5º do art. 128, ambos da Carta Magna.

Nessa senda, imaginemos que o sindicato dos servidores civis da União inicie um conjunto de reivindicações perante o Congresso Nacional para aprovar nova lei que altere seu regime de vantagens. Todo o debate político e público estaria voltado apenas para os servidores da União. Sendo aprovada a lei, ela criaria um **efeito cascata** na medida em que tudo que fora deliberado e aprovado para os servidores civis, seria, sem ninguém perceber, estendido aos membros do MP, por força de uma regra aglutinadora de legislações para carreiras tão distintas.

Assim, a hipotética lei violaria o princípio da legalidade porque o que se decidiu foi modificar a lei dos servidores civis da União e não dos membros do MP, que sequer se enquadram na categoria "servidores públicos" e sim na de "agentes políticos".

A prevalecer tal interpretação, 'data venia', várias regras jurídicas seriam criadas sem prévia manifestação expressa de decisão majoritária. Em outras palavras, estar-se-ia alterando substancialmente um regime jurídico (dos membros do MP) sem que esse tema tenha constituído objeto de deliberação no Poder Legislativo. Cunha-se, com esta situação, afronta ao princípio do devido processo legislativo e da publicidade, que impõem um dever de transparência nas decisões do Estado.

Por essas razões, os citados dispositivos legais devem receber uma interpretação conforme à Constituição.

É que a legislação NACIONAL permite que os membros do Ministério Público dos Estados recebam vantagens existentes em lei para os servidores da União.

No entanto, para que isso ocorra cada Estado, no âmbito de sua autonomia e capacidade financeira, decidiria, por lei, sobre a implantação de uma nova vantagem aos membros do MP-PE. Logo, a percepção do auxílio-alimentação por parte dos membros do MP/PE seria, em tese, lícita, **desde que prevista em lei estadual**.

Assim, neste ponto, **a norma contida na Lei Federal nº 8.625/93,** que estende aos membros do Ministério Público as vantagens recebidas por demais servidores, **deve ser interpretada em conformidade com a Constituição Federal, ou seja, com o princípio da legalidade e da reserva legal, exigindo-se lei específica estadual para a instituição da vantagem.**

É cediço que a CF/88 deu nova conformação ao Ministério Público: concedeu-lhe instrumentos para que sua função constitucional fosse desempenhada com independência e autonomia. Além de garantias institucionais (autonomia administrativa e financeira; iniciativa de lei) foram conferidos aos seus integrantes irredutibilidade de subsídios, inamovibilidade, independência funcional e vitaliciedade, tudo de modo a permitir que os membros da instituição pudessem defender o primado do Estado Democrático de Direito e os interesses da sociedade.

Em síntese, a Carta Magna municiou o Ministério Público, bem como seus integrantes, com as garantias necessárias a sua independência orgânica e funcional.

Seguindo a mesma orientação, o constituinte reformador, mediante a EC nº 45/04, fixou as garantias e vedações do *Parquet*, bem como os princípios e regras gerais que deverão nortear os Estatutos desta categoria profissional.

Deve-se enfatizar que a Constituição Federal, no que concerne ao Ministério Público, não estatui benefícios de classe, nem verbas indenizatórias, mas prerrogativas que visam assegurar o desempenho da atividade dos membros do MP com liberdade, independência e imparcialidade.

A Constituição, ao fazê-lo, quis estabelecer meios de garantir que os promotores e procuradores de justiça possam servir à coletividade, e, por esse

motivo, não cuidou de regulamentar os benefícios e as verbas indenizatórias devidas, tarefa que ficou a cargo da legislação infraconstitucional.

Em 1993, anos antes da EC nº 45/04, foi editada a Lei Orgânica do Ministério Público da União (Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993), que previu expressamente as vantagens a serem concedidas aos membros ministeriais e deixou bem claro:

> *Art. 224. Os membros do Ministério Público da União receberão o vencimento, a representação e* ***as gratificações previstas em lei****.*

Logo, o que se verifica é que o Ministério Público da União, por sua lei própria, **não possui** auxílio-alimentação previsto, sendo tal benefício pago por um *entendimento* daquela classe de estender vantagens dos servidores públicos civis aos agentes políticos, que são os membros do MP, **igualando, inconstitucionalmente, regimes jurídicos absolutamente distintos**.

Observe-se, contudo, que quando da edição da EC nº 45/04, a Lei Federal nº 8.460, de 17 de setembro de 1992 (que organiza os servidores públicos federais), já existia (art. 22). Ora, caso o constituinte desejasse estender aos membros do Ministério Público um benefício que já era pago aos servidores, tê-lo-ia feito expressamente e não elaborado fórmula no mínimo lacônica.

Em síntese, **a norma federal diz que são devidas aos membros do MP as vantagens previstas aos demais servidores, em caráter geral, mas essa extensão não pode dispensar lei específica.** Todavia, no caso de Pernambuco, foi estabelecida por meio de uma Resolução do Procurador-Geral de Justiça.

Mais precisamente: Resolução expedida após sessão do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado de Pernambuco, a qual instituiu o auxílio-alimentação, e Portaria do Procurador-Geral de Justiça definiu o valor a ser pago (R$ 1.068,00).

Esse e. Supremo Tribunal Federal possui precedente que, igualmente, pode ser bem aplicado ao caso:

"Por ofensa ao princípio da reserva de lei formal para concessão de aumentos aos servidores públicos (CF, art. 61, § 1º, II, a), o Tribunal declarou de ofício a inconstitucionalidade do art. 10 da Lei nº 7.673/95, do Município de Fortaleza, que, ao instituir a Gratificação de Aumento de Produtividade, delegou ao Executivo, sem quaisquer parâmetros, a definição de sua disciplina ("Fica instituída gratificação relativa à produtividade dos integrantes do quadro de Procuradores do Município, na forma do Decreto a ser baixado pelo Chefe do Poder Executivo,..."), e do Decreto nº 9.643/95, que o regulamentou. Tratava-se, na espécie, de recurso extraordinário em que se pretendia ver reconhecido o direito de procuradores inativos à percepção da referida vantagem por força do art. 40, § 4,º da CF, na redação original – que determinava a extensão aos inativos de quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade. O Tribunal, considerando que a extensão prevista no art. 40, § 4º da CF pressupõe a validade da lei instituidora da vantagem, não conheceu do recurso extraordinário. RE 264-CE, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 3.10.2001. (RE-264289)"

Assim, não é possível entender que a Lei Federal nº 8.625/93, por uma singela previsão de que os Membros do Ministério Público possuem direito às mesmas vantagens previstas aos demais servidores públicos, teria o condão de estabelecer, **por mera remissão**, a aplicação, no âmbito estadual, do aludido auxílio-alimentação, já extraído em norma remissiva, de extensão, no art. 287 da Lei Complementar nº 75/93.

Como todo respeito, tal posição significa remissão da remissão. E mais grave: disciplinada por Resolução do Procurador-Geral de Justiça.

Caso se reconheça a legitimidade do MP-PE em criar o auxílio-alimentação para seus membros por Resolução, por coerência, há de lhe ser reconhecido o poder de colmatar todas demais lacunas que identificar na em sua Lei Orgânica (Lei Complementar Estadual nº 12/94[4]) ou em qualquer outra lei que se relacione com a organização e estrutura do Ministério Público.

Portanto, a interpretação das normas combatidas é inconstitucional também por invadir o campo da reserva de lei.

[4] Que, inclusive, só prevê pagamento para fins de despesas alimentares no art. 59, V:
"*Art. 59 - Alem dos vencimentos, são outorgadas aos membros do Ministério Público as seguintes vantagens:*
[...]
*V - **diárias, por deslocamento em serviço, para fora da sede de lotação**, para atender despesas de alimentação e pousada, calculando-se cada um em 1/30 (um trinta avos) e 2/30 (dois trinta avos) dos vencimentos do cargo, se o deslocamento se der, respectivamente, dentro ou fora do Estado;*"

Eis, por conseguinte, a segunda inconstitucionalidade:

* Considerando que a mera previsão genérica no art. 80 ou mesmo no art. 50 da Lei Federal nº 8.625/93 não tem o condão de, automaticamente, conceder o auxílio-alimentação aos membros do MP-PE, não poderia tal regra ser aplicada para legitimar a competência do Procurador-Geral de Justiça (PGJ) no estabelecimento de tal vantagem aos próprios membros do MP-PE, por meio de simples Resolução. Conclui-se, assim, que falece tal competência ao PGJ para editar Resolução implantando auxílio-alimentação aos Promotores e Procuradores de Justiça. **Inconstitucionalidade demonstrada por ferir o art. 37, *caput*, da Constituição Federal (princípio da legalidade), e § 5º do art. 128 do referido Diploma**:

*"Art. 37. **A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade**, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)*
[...]

Art. 128. [...]
[...]
*§ 5º - **Leis complementares da União e dos Estados**, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, **estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público**, observadas, relativamente a seus membros:"*

Pede-se, por conseguinte, seja dada interpretação conforme ao art. 22 'caput' e §§ 1º ao 3º, alíneas "a", "b", "c", e §§ 4º ao 8º da Lei Federal nº 8.460/92; ao art. 50 'caput' e inciso XII e art. 80 da Lei Federal nº 8.625/1993; bem como ao art. 287 'caput' e § 1º da Lei Complementar nº 75/93, nos termos já requeridos e por consequência declaradas inconstitucionais as Resoluções atacadas.

III.III – DA REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO COMO PARCELA ÚNICA E INCOMPATIBILIDADE DE RECEBIMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO:

Outro aspecto a ser considerado é a alteração, implementada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998, sobre a forma de remuneração dos

membros do Ministério Público, que devem receber pela via de subsídio, vedado qualquer acréscimo de vantagem.

O auxílio-alimentação passou a ser pago aos membros do Ministério Público da União em 1993, conforme consignado na Resolução ora impugnada, *ex vi* Portaria nº 586, de 18/12/1992. A fundamentação se deu com base no art. 287 da Lei Complementar nº 75/1993.

Ocorre que em 1992 foi publicada a Lei nº 8.460, disciplinando uma vantagem em caráter geral aos servidores públicos civis da União, fato este que fez incidir o art. 287 e, consequentemente, uma norma de extensão a favor dos Membros do MPU.

Naquela época, 1992 e 1993, os membros do MPU recebiam remuneração constituída de vencimento base e outras gratificações. Ou seja, recebiam como "vencimentos", e não como "subsídio".

Contudo, após o advento da EC nº 19/98 os membros do Ministério Público passaram a receber por meio de *subsídio*, que é, justamente, uma parcela única. É o que diz o art. 39, 4º, da Constituição Federal de 1988, *verbis:*

> *§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.*

Com base na reforma constitucional, os dois sistemas de remuneração (demais servidores públicos e membros do Ministério Público) passaram a divergir. Os primeiros continuaram recebendo por vencimentos (em vencimentos, inclui-se o vencimento-base + gratificações ou vantagens[5]), enquanto a segunda categoria, de membro do Ministério Público, passou a receber por meio de subsídio.

A partir de tal data, então, não é possível aplicar um sistema híbrido aos membros do Ministério Público, ou seja, estender-lhes outras vantagens do sistema remuneratório dos demais servidores públicos, haja vista

[5] *Vide* art. 1º da Lei Ordinária Federal nº 8.852, de 4 de fevereiro de 1994.

que o constituinte reformador foi expresso ao utilizar a expressão *subísidio em parcela única,* daí a impossibilidade de acumulação de outras vantagens em plena desnaturação do modelo definido na Carta da República.

A rigor, a partir da implementação dos subsídios aos membros do Ministério Público deveria ter sido suspenso o pagamento da vantagem do auxílio-alimentação, regra que lhes era aplicável em uma época em que tais membros, assim como os demais servidores públicos, recebiam por meio de vencimentos, e não subsídios.

Considerando que a forma de remuneração por vencimentos possibilita a fragmentação de rubricas no salário (veja-se que algumas categorias que ganham R$ 2.000 possuem, como vencimento-base, R$ 700,00, sendo o restante fragmentado em diversas rubricas), é plausível sustentar a liberdade de a Administração Pública instituir a vantagem do auxílio-alimentação para ser acrescido, como mais uma rubrica, aos vencimentos recebidos pelo servidor público.

Já no caso do agente político que recebe por subsídio o raciocínio não se aplica, pois recebe em parcela única e, naturalmente, naquela única parcela deve estar previsto o valor para que o agente possa manter a sua subsistência e a da sua família, inclusive subsistência alimentar, sob pena de desvirtuamento da *mens legislatoris*.

É da própria natureza do subsídio ser único – foi para isto que ele foi criado:

> ***Com o intuito de tornar mais visível e controlável a remuneração de certos cargos, impedindo que fosse constituída por distintas parcelas que se agregassem de maneira a elevar-lhes o montante, a Constituição criou uma modalidade retributiva denominada subsídio.***
> ***Subsídio é a denominação atribuída à forma remuneratória de certos cargos, por força da qual a retribuição que lhes concerne se efetua por meio dos pagamentos mensais de parcelas únicas, ou seja, indivisas e insuscetíveis de aditamento ou acréscimos de qualquer espécie. […].***
> ***Assim, na vedação estabelecida só se incluem as verbas indenizatórias, qual, por exemplo, o pagamento de 'ajudas de custo' para acobertar despesas de mudança do servidor designado para servir em local fora da sede.***

(MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 27ª ed. rev. e atual. até a Emenda Constitucional 64, de 4.2.2010. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 277, grifo original).

Corroborando o entendimento esposado:

A primeira razão da exigência de parcela única consiste em afastar essa duplicidade de parcelas que a tradição configurava nos subsídios.
A proibição expressa de acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória reforça o repúdio ao conceito tradicional e elimina o vezo de fragmentar a remuneração com múltiplos penduricalhos, que desfiguram o sistema retributório do agente público, gerando desigualdades e injustiças. Mas o conceito de parcela única só repele os acréscimos de espécies remuneratórias do trabalho normal do servidor público.
Não impede que ele aufira outras verbas pecuniárias que tenham fundamentos diversos, desde que consignados em normas constitucionais.
Ora, o § 3º do art. 39, remetendo-se ao art. 7º, manda aplicar aos servidores ocupantes de cargos públicos (não ocupantes de mandato eletivo, de emprego ou funções públicas) algumas vantagens pecuniárias, nele consignadas, que não entram naqueles títulos vedados[6]. […]"
(SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 33ª ed. rev. e atual. até a Emenda Constitucional nº 62, de 9.11.2009, publicada em 12.12.2009. São Paulo: Malheiros, 2010, grifo original – Neste mesmo sentido: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 536).

E ainda:

"Registre-se a intenção de se acabar com o sistema remuneratório que vinha vigorando desde a promulgação do Texto de 1988. ***A partir de agora, as mesmas categorias de agentes públicos não poderão perceber o padrão fixado em lei mais as famosas 'vantagens pecuniárias previstas nos estatutos'****.*

[6] *Nesse mesmo sentido é a doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello (sobre o § 3º do art. 39, combinado com o art. 7º, da Constituição Federal): "Anote-se que ditas observações só valem para os servidores públicos, não abrangendo os agentes políticos, pois é apenas dos primeiros que cogita o art. 39, § 3º." (Curso…, p. 277, grifo original).*

> *Daí o dispositivo vedar expressamente "o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória".*
> ***Conseqüência disso: para os agentes que recebem subsídios ficam derrogadas todas as normas infraconstitucionais que prevejam vantagens pecuniárias remuneratórias como parte da remuneração**."*
> *(BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal Anotada. 9. ed. rev. e atual. até a Emenda Constitucional nº 57/2008. São Paulo: Saraiva, 2009, grifo nosso).*

Observa-se, então, que **o auxílio-alimentação instituído pela Resolução do Procurador-Geral de Justiça possui caráter geral,** sendo devido a todos os membros do Ministério Público do Estado de Pernambuco, independentemente de comprovação ou prestação de contas.

É, na verdade, um aumento de salário travestido de auxílio-alimentação, pois, materialmente a sua natureza não é indenizatória, ao contrário da exegese extensiva e da posição do e. Conselho Nacional do Ministério Público - CNPM ao editar a Resolução nº 09/2006.

Com todo respeito, o estabelecimento de tal vantagem não busca recompor o prejuízo do membro do MP com algum custo que tenha tido em razão do exercício profissional, como, por exemplo, é o caso de diárias por deslocamento a serviço (caso típico de natureza indenizatória – art. 59, V, da Lei complementar estadual nº 12/94).

Ao revés. **O auxílio-alimentação, sendo concedido em caráter geral, perde a sua natureza de verba indenizatória e passa a ser uma burla ao sistema de remuneração pela técnica do subsídio,** que deve ser uma parcela única de padrão remuneratório, *concessa máxima venia*.

Consequentemente, eis a terceira inconstitucionalidade, especialmente observada na resolução combatida:

> * As vantagens concedidas a servidores públicos, previstas em lei, são-lhes devidas em função da aplicação de um padrão remuneratório de "vencimentos", o que permite a fragmentação das diversas rubricas que compõem o quadro "salário". Já no que diz respeito ao pagamento por subsídio, o membro do Ministério

Público o recebe em única parcela, não fragmentada, que já é elaborada contando com a despesa alimentar a ser desembolsada.

De fato, a partir do momento em que os membros do Ministério Público passaram a receber por subsídios não pode ser a eles aplicadas as vantagens concedidas aos demais servidores públicos que recebem ainda por vencimentos (VB – vencimento base – somado a outras vantagens), razão pela qual se conclui que as Resoluções impugnadas não se coadunam com os termos da Emenda Constitucional nº 19/98, já que incompatíveis com o sistema de remuneração por meio de subsídios.

Ademais, considerando que o salário já possui, em si, a natureza alimentar, a instituição de auxílio-alimentação, como vantagem adicional ao subsídio, seria apenas possível uma vez caracterizada a extraordinariedade no desempenho da função (como, por exemplo, pagamento de diárias para cobrir custos de deslocamento com alimentação e hospedagem fora da localidade habitual de prestação do serviço). Esse é o caso do art. 59, inciso V, da Lei Complementar Estadual nº 12, que prevê pagamento de diárias para cobrir custos com alimentação, desde que o membro do MPE esteja em viagem.

Consequentemente, conceder por Resolução auxílio-alimentação em caráter geral, a quem já recebe subsídio, seria um *bis in idem*, caracterizando, a rigor, um aumento salarial camuflado de "indenização". Logo, além de violar o novo regime de remuneração criado pela EC nº 19/98 **(§4º do art. 39 da CF/88), atinge art. 37, *caput* (princípio da moralidade na Administração Pública)**.

Requer-se seja dada interpretação conforme ao art. 22 'caput' e §§ 1º ao 3º, alíneas "a", "b", "c", e §§ 4º ao 8º da Lei Federal nº 8.460/92; ao art. 50 'caput' e inciso XII e art. 80 da Lei Federal nº 8.625/1993; bem como ao art. 287 'caput' e § 1º da Lei Complementar nº 75/93, nos termos já requestados e, por consequência, declaradas inconstitucionais as Resoluções atacadas.

IV – DO PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR:

No caso presente, a concessão da cautelar é medida que se impõe, estando presentes seus pressupostos autorizadores porque os normativos ora questionados quebram a confiança dos administrados na natureza republicana das instituições democráticas ao criarem benefícios descabidos e

especiais, desvirtuando, portanto, o regime remuneratório instituído para os membros do Ministério Público.

Outrossim, é evidente a existência do *fumus boni juris*, que, *in casu,* é translúcido e pode ser observado e provado por meio de simples leitura dos precedentes jurisprudenciais utilizados como paradigmas, reforçado por toda a argumentação e fundamentação acima expostas.

De igual sorte, patente o *periculum in mora*, visto que a vantagem, uma vez concedida e percebida, muito dificilmente poderá ser desfeita, sendo de difícil recuperação aos cofres públicos.

E a matéria, no mais, já ganhou repercussão na mídia, em especial em face do montante de recursos públicos que serão e que são aplicados pelo Estado de Pernambuco em razão da Resolução ora atacada.

Isto é, chegou até a receber o apelido popular de "*Auxílio-Spettus*", em referência a um restaurante de grande porte existente no Estado.

> *GASTOS PÚBLICOS*
> ***Auxílio-alimentação do MPPE não exige nota fiscal***
> ***Procurador Aguinaldo Fenelon sai em defesa e avisa que benefício "não será revisto"***
> *Publicado em 19/02/2012, às 17h00*
> *Sheila Borges*
> *O procurador-geral do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), Aguinaldo Fenelon, defendeu a concessão do auxílio-alimentação no valor de R$ 1.068,00 mensais a todos os membros do órgão e, em rápida entrevista ao **JC**, garantiu que o mesmo "não será revisto".*
> *Na entrevista, Fenelon – que desde que a notícia havia sido divulgada pelo **JC**, na última quinta-feira (15), ainda não havia falado sobre o assunto –, terminou admitindo um diferencial em relação a outros órgãos: o auxílio-alimentação do MPPE será depositado diretamente no salário dos procuradores e promotores, que não precisarão comprovar os gastos com notas fiscais. Na prática, eles também estarão desobrigados de usar a verba exclusivamente para refeições.*
> *Em outros órgãos do Estado, o benefício funciona como verba indenizatória, quando o funcionário cobre a despesa a partir de seu próprio bolso e só é ressarcido após prestar contar do que foi gasto, mediante a apresentação de notas fiscais. No MPPE, o auxílio-alimentação valerá a partir de março – conforme portaria publicada na quarta-feira (16) no Diário Oficial.*
> *De acordo com Fenelon, que falou ao **JC** no sábado (18), durante café da manhã no Palácio do Campo das Princesas, antes do desfile do Galo da*

Madrugada, Pernambuco era um dos poucos Estados onde os funcionários do Ministério Público não tinham ainda direito a receber o auxílio-alimentação. O valor indicado na portaria é maior do que o aplicado pelo Tribunal de Contas do Estado (R$ 900) e pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (R$ 630).

A medida beneficiará 376 promotores e procuradores e causará, por ano, um acréscimo de R$ 4,8 milhões nas despesas do MPPE. Mesmo ciente da repercussão negativa do ato, Fenelon disse que respeita as opiniões contrárias, mas assegurou que o valor não será revisto.

(Jornal do Commercio – Política – http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/politica/noticia/2012/02/19/auxilio-alimentacao-do-mppe-nao-exige-nota-fiscal--32862.php)

As notícias anexas, 'data venia', dão conta que além de criar e conceder o auxílio-alimentação a todos os membros do Ministério Público do Estado de Pernambuco, o Procurador-Geral de Justiça se comprometeu a pagar valores retroativos de 2007 a 2012, o que representa despesa adicional na ordem de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais) para cada integrante do Ministério Público Estadual.

Um retroativo de R$ 65 mil no MPPE

GASTOS PÚBLICOS A verba - de auxílio-alimentação – será paga aos 362 membros do Ministério Público de Pernambuco, o que resultará em um custo total de R$ 23,5 milhões

Bruna Serra
bserra@jc.com.br

Na contramão da demanda social de racionalização do gasto público, o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) pagará R$ 65 mil em benefício a cada um dos seus 362 membros. A decisão do procurador-geral de Justiça, Aguinaldo Fenelon, de pagar auxílio-alimentação retroativo de 2007 a 2012 aos promotores e procuradores do órgão foi publicada ontem no Diário Oficial. Atualmente, os membros do MPPE ganham R$ 1,1 mil mensais para custear suas despesas com alimentação – R$ 55 reais por dia útil em gastos.

Na segunda-feira (25/2) os quarenta membros do Colégio de Procuradores do Ministério Público se reuniram em sessão plenária que aprovou o pagamento do auxílio retroativo no período de março de 2007 a fevereiro de 2012, por 34 votos favoráveis ao pagamento do benefício e apenas 6 contrários. O pagamento será retroativo a 2007 por ser o ano em que o Supremo Tribunal Federal (STF) considerou legal o subsídio aos integrantes do órgão.

Cada um dos 362 integrantes receberá neste mês de março uma primeira parcela no valor de R$ 13 mil, os outros R$ 52 mil serão quitados de forma parcelada ainda a ser estudada para "caber" no orçamento do MPPE que, em 2013, é de R$ 650 milhões ou 2% dos R$ 31 bilhões previstos do orçamento do governo estadual. Além do pagamento retroativo do auxílio-alimentação, os membros do Ministério Público também estão aguardando a aprovação pela Assembleia Legislativa de Pernambuco do reajuste mensal de 5%, retroativo a janeiro de 2013. O reajuste do salário é baseado no Orçamento-Geral da União para 2013 que ainda nem foi aprovado pelo Congresso Nacional.

O procurador Aguinaldo Fenelon foi procurado pelo **JC**, mas sua assessoria informou que ele não poderia dar esclarecimentos sobre o benefício que terá um impacto de R$ 23,5 milhões sobre a folha de pagamento do órgão porque estava em trânsito para Brasília. Em nota, a assessoria informou que "o auxílio-alimentação baseia-se em um procedimento já adotado nas unidades de outros Estados, havendo sito editada, inclusive, a Resolução 133 do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) reconhecendo o direito à percepção desse benefício por membros do Judiciário em observância à paridade vencimental entre o Judiciário e o MP".

Como o despacho trata-se do acolhimento de um parecer positivo expedido pela Assessoria Técnica Ministerial Administrativa (ATMA) do MPPE, um servidor do quadro técnico da casa foi escalado para dar mais informações sobre a decisão de Fenelon na tarde de hoje. O procurador permanece em Brasília.

AÇÃO DA OAB

Em setembro de 2012, o Conselho Federal da OAB aprovou o ajuizamento de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) para questionar a resolução do Ministério Público de Pernambuco, que concede a promotores e procuradores de justiça o auxílio-alimentação. A decisão foi tomada com base no voto do relator, o conselheiro Manoel Bonfim, por proposição da Seccional pernambucana, que ontem preferiu não se manifestar. A Adin ainda não foi julgada.

Em números exatos, 'data venia', **significa despesa adicional do Erário Estadual na ordem de R$ 23,5 milhões para um total de 362** (trezentos e sessenta e dois) **beneficiados, o que representa custo per capita de R$ 65 mil.**

Também segundo a imprensa local, **a primeira parcela será paga no fim desse mês de março/13, ao valor unitário de R$ 13.000,00** (treze mil reais), sem contar os R$ 1.068,00 mensais que os membros do MP-PE já estão recebendo.

O tema versado na presente ação, sob outro aspecto, é por demais relevante, já que se está diante de matéria que envolve a própria ossatura institucional do Estado.

A **urgência qualificada,** pois, diante de tal quadro fático, **enseja a imediata apreciação e concessão da medica cautelar 'ad referendum' do Plenário**, e na trilha de precedentes dessa egrégia Suprema Corte tomado por ocasião do julgamento da ADI 437-9, a liminar dever ser concedida, **verbis:**

> *"No que respeita ao "periculum im mora", é orientação desta corte que, em se tratando de pagamento de servidores, com base em norma que possa ser tida com inconstitucional, deve o pagamento ser suspenso, pelo risco da difícil recuperação, por parte da fazenda, de um eventual dano decorrente do pagamento a servidores, por tempo que normalmente se faz longo, até o julgamento final de ação, de quantias indevidas. Dentro dessa compreensão global da matéria, acompanho o eminente relator. Defiro também a medida liminar."(JSTF – Lex – 177/23)*

Nesse sentido, válido recordar que este C. Supremo Tribunal Federal já se deparou com idêntica situação:

> *"(...)*
> ***Rp 1392 MC / RS - RIO GRANDE DO SUL***
> ***MEDIDA CAUTELAR NA REPRESENTAÇÃO***
> ***Relator(a): Min. SYDNEY SANCHES***
> ***Julgamento: 18/03/1987 Órgão Julgador: TRIBUNAL PLENO***
> ***Publicação**: DJ 10-04-1987 PP-06417 EMENT VOL-01456-01 PP-00084*
> ***Ementa - REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE** - EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL, SOB N. 40, DE 28-10-1986, QUE, NO ARTIGO 3., ACRESCENTANDO PARAGRAFOS AO ARTIGO 153 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO,*

DISPOS SOBRE SUBSIDIOS MINIMOS DEVIDOS AO PREFEITO E AO VICE-PREFEITO DOS MUNICÍPIOS E PARA VIGORAR DENTRO DA MESMA LEGISLATURA. ***REPRESENTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA, COM ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTIGOS 13, III, 15, PARAGRAFO 2., 44, VII, 57, II, TODOS C/C ARTIGO 200 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DA EFICACIA DE TAL NORMA CONSTITUCIONAL ESTADUAL (ARTIGO 3. DA E.C. N. 40). PRESENTES OS REQUISITOS DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO ('FUMUS BONI IURIS'), DO RISCO DA DEMORA NO JULGAMENTO ('PERICULUM IN MORA'), COM POSSIBILIDADE DE GRAVE DANO AO ERARIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS GAUCHOS, DE DIFICIL REPARAÇÃO, DEFERE-SE A MEDIDA CAUTELAR REQUERIDA, ATÉ JULGAMENTO FINAL DA REPRESENTAÇÃO.***
(...)"

Recentemente, na ADI 4307[7] o Pleno referendou liminar concedida pela e. Min. CÁRMEN LÚCIA contra a chamada 'PEC DOS VEREADORES' --- EC nº 59/2009 ---, cuja situação fático-jurídico se assemelha ao caso presente. Ou seja, possibilidade de recebimento de valores e prejuízos ao Erário de forma irreversível, porquanto eventuais pagamentos realizados dificilmente serão revertidos na hipótese de procedência dos pedidos.

[7] **EMENTA:** AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 58/2009. ALTERAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DOS LIMITES MÁXIMOS DAS CÂMARAS MUNICIPAIS. ART. 29, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RETROAÇÃO DE EFEITOS À ELEIÇÃO DE 2008 (ART. 3º, INC. I). POSSE DE VEREADORES. VEDADA APLICAÇÃO DA REGRA À ELEIÇÃO QUE OCORRA ATÉ UM ANO APÓS O INÍCIO DE SUA VIGÊNCIA: ART. 16 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA, COM EFEITOS '*EX TUNC*', PARA SUSTAR OS EFEITOS DO INCISO I DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 58, DE 23.9.2009, ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DA PRESENTE AÇÃO.
1. Cabimento de ação direta de inconstitucionalidade para questionar norma constante de Emenda Constitucional. Precedentes.
2. Norma que determina a retroação dos efeitos das regras constitucionais de composição das Câmaras Municipais em pleito ocorrido e encerrado afronta a garantia do pleno exercício da cidadania popular (arts. 1º, parágrafo único e 14 da Constituição) e o princípio da segurança jurídica.
3. Os eleitos pelos cidadãos foram diplomados pela justiça eleitoral até 18.12.2009 e tomaram posse em 2009. Posse de suplentes para legislatura em curso, em relação a eleição finda e acabada, descumpre o princípio democrático da soberania popular.
4. Impossibilidade de compatibilizar a posse do suplente não eleito pelo sufrágio secreto e universal: ato que caracteriza verdadeira nomeação e não eleição. O voto é instrumento da democracia construída pelo cidadão: impossibilidade de afronta a essa expressão da liberdade de manifestação.
5. A aplicação da regra questionada importaria vereadores com mandatos diferentes o que afrontaria o processo político juridicamente perfeito.
6. Medida cautelar concedida referendada.

Com todo respeito, a sequência dos acontecimentos e a melhor hermenêutica do sistema constitucional brasileiro, seus valores e normatizações, demonstram o bom direito a ser resguardado *in limine*.

Os prejuízos ao Erário com o pagamento de tais 'benefícios' já se alongam e tornar-se-ão maiores com a delonga na análise do pleito cautelar.

Neste contexto fático, além de presente a conveniência da suspensão liminar da eficácia do ato normativo impugnado em face da relevância qualificada e profiláctica, atrelado à plausibilidade jurídica do direito invocado, faz-se presente o "*periculum in mora"*.

Impõe-se, assim, **a concessão de liminar ao final requerida *'ad referendum'* do Plenário, na trilha da orientação desta Egrégia Corte[8], a fim de se conferir interpretação conforme aos dispositivos impugnados na forma já delimitada, bem como seja suspensa a eficácia da íntegra da Resolução RES-PGJ nº 002/2012 do Ministério Público do Estado de Pernambuco.**

V - DOS PEDIDOS:

Pelo exposto, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil **requer**:

a) a) a notificação da **PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA,** da **CÂMARA DOS DEPUTADOS,** do **SENADO FEDERAL,** do **CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP,** por intermédio de seus Presidentes, e a notificação do **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO,** por intermédio do Procurador-Geral de Justiça, para que, como responsáveis pela elaboração das normas impugnadas, manifestem-se, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido de concessão de medida cautelar, com base no art. 10 da Lei nº 9.868/99;

[8] *"Ação Direta de Inconstitucionalidade.§1º do artigo 29 da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. – **relevância da fundamentação jurídica da argüição de inconstitucionalidade (ofensa à iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo quanto a projeto de lei sobre regime jurídico** e aposentadoria de servidor público civil), **bem como ocorrência do requisito de conveniência para a concessão da liminar. Pedido e liminar deferido para suspender, "ex nunc"**, a eficácia do §1º do artigo 29 da Constituição do Rio Grande do Norte até a decisão final da presente ação. (STF – ADIMC – 1730/RN, rel. Min. Moreira Alves, J. em 18/06/98, unânime tribunal pleno, DJ de 18/09/98, pagina 002)*

b) a concessão de medida cautelar, com base no art. 10 da Lei nº 9.868/99, para que seja dada **interpretação conforme** à Constituição Federal ao art. 22 'caput' e §§ 1º ao 3º, alíneas "a", "b", "c", e §§ 4º ao 8º da Lei Federal nº 8.460/92; ao art. 50 'caput' e inciso XII e art. 80 da Lei Federal nº 8.625/1993;bem como ao art. 287 'caput' e § 1º da Lei Complementar nº 75/93, para que seja consignado que **o auxílio-alimentação subsidiariamente conferido aos membros do Ministério Público da União não se aplica AUTOMATICAMENTE aos membros do Ministério Público dos Estados, restando indispensável a edição de lei em sentido estrito para esse desiderato, e por consequência seja suspensa a eficácia da íntegra da Resolução RES-PGJ nº 002/2012 do MP-PE,** que instituiu o benefício do auxílio-alimentação aos Promotores e Procuradores de Justiça de Pernambuco, em reconhecimento da inconstitucionalidade por arrastamento;

c) a notificação da **PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA,** da **CÂMARA DOS DEPUTADOS,** do **SENADO FEDERAL,** do **CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CNMP,** por intermédio de seus Presidentes, e a notificação do **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO,** por intermédio do Procurador-Geral de Justiça, para que, como responsáveis pela elaboração das normas impugnadas, manifestem-se, querendo, sobre o mérito da presente ação, no prazo de trinta dias, nos termos do art. 6º, parágrafo único da Lei nº 9.868/99;

d) a notificação do Exmo. Sr. Advogado-Geral da União para se manifestar sobre o mérito da presente ação, nos termos do Art. 8º da Lei nº 9.868/99 e da exigência constitucional do Art. 103, § 3º;

e) a notificação do Exmo. Sr. Procurador Geral da República para que emita o seu parecer, nos termos do art. 103, § 1º da Carta Política;

f) a procedência do pedido de mérito para que seja dada **interpretação conforme à Constituição Federal** ao art. 22 'caput' e §§ 1º ao 3º, alíneas "a", "b", "c", e §§ 4º ao 8º da Lei Federal nº 8.460/92; ao art. 50 'caput' e inciso XII e art. 80 da Lei Federal nº 8.625/1993; bem como ao art. 287 'caput' e § 1º da Lei Complementar nº 75/93, para que seja consignado que **o auxílio-alimentação subsidiariamente conferido aos membros do Ministério Público da União não se aplica AUTOMATICAMENTE aos membros do Ministério Público dos Estados, restando indispensável a edição de lei em sentido estrito para esse desiderato e,** por consequência, **seja declarada a inconstitucionalidade da íntegra da Resolução RES-PGJ nº 002/2012 do**

MP-PE, que instituiu o benefício do auxílio-alimentação aos Promotores e Procuradores de Justiça de Pernambuco, em reconhecimento da inconstitucionalidade por arrastamento.

Deixa-se de atribuir valor à causa, em face da impossibilidade de aferi-lo.

Nesses termos, pede deferimento.

Brasília/DF, 22 de março de 2013.

Marcus Vinicius Furtado Coêlho
Presidente do Conselho Federal da OAB

Oswaldo Pinheiro Ribeiro Júnior
OAB/DF 16.275

Rafael Barbosa de Castilho
OAB/DF 19.979